

1502555-36.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... afastou a hediondez no delito de tráfico de entorpecentes privilegiado: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502555-36.2021.8.26.0597

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2175170/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 13339996 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 1463/21/907 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2175170 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO EZEQUIEL ROQUE

PROCESSO DIGITAL

Aos 23 de fevereiro de 2022, às 15:20 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito, Dra. PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: o representante do Ministério Público, Dr. JOÃO GUIMARÃES COZAC; a advogada nomeada do réu, Dra. DANIELA MERMEJO JERÔNIMO, OAB/SP nº 178.691; o réu DIOGO EZEQUIEL ROQUE; e as testemunhas de acusação DANILO CARVALHO DE ATAÍDE e SÔNIA REGINA PETRI DOMINGOS. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), estando todos os prédios do fórum fechados, tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas de acusação DANILO CARVALHO DE ATAÍDE e

SÔNIA REGINA PETRI DOMINGOS, bem como foi interrogado o acusado DIOGO EZEQUIEL ROQUE. A MM. Juíza tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pela MM. Juíza foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, que ficam armazenadas no sistema SAJ. Após, pela MM. Juíza foi proferida sentença: "Vistos. DIOGO EZEQUIEL ROQUE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 05 de junho de 2021, às 22h45min, em via pública, na Rua Edmundo Teixeira, nº 440, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sertãozinho/SP, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções de "Cannabis sativa L", substância vulgarmente conhecida como "maconha", além de 36 (trinta e seis) cápsulas de cocaína. Narra a denúncia que, na ocasião dos fatos, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local, o qual é conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Ato contínuo, o indivíduo foi identificado como DIOGO, sendo encontrada em sua posse 1 (uma) poção de maconha e 4 (quatro) cápsulas de cocaína, além da quantia de R\$170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas diversas. Ainda, vasculhando o local, os agentes encontraram, nas proximidades de DIOGO e dentro de um buraco na calçada, outras 32 (trinta e duas) porções de cocaína e outras 7 porções de maconha, todas embaladas e acondicionadas de forma idêntica às que estavam em sua posse. A denúncia foi recebida no dia 07 de dezembro de 2021 (páginas 60/61) veio acompanhada de inquérito policial e documentos. Regularmente citado (certidão de página 73), o acusado ofereceu defesa escrita (página 78/80). Às páginas 82/83 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao acusado. Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, realizado o interrogatório do acusado. Em sede de debates orais, a Ilustre representante do Ministério Público protestou pela procedência integral da presente ação penal, delineando a prova colhida nos autos e tecendo considerações sobre a dosimetria da pena. Ao final, requereu a decretação do perdimento de valores apreendidos. A Nobre Defesa, por sua vez, também em sede de debates orais, protestou pela absolvição do acusado sob o fundamento, em resumo, de ausência de prova suficiente para o decreto condenatório, apontando que a droga apreendida em sua posse seria destinada ao uso exclusivo do acusado. Subsidiariamente, protestou pela desclassificação do delito de tráfico para o de porte de drogas. No mais, teceu considerações sobre a dosimetria da pena, em caso de condenação. É o relatório. Fundamento e decido. O acusado está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Após análise detida das provas constantes do caderno processual tem-se que a presente ação penal é procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 03/05), pelo auto de exibição e apreensão de droga (páginas 09/10), pelos registros fotográficos (páginas 11/14), pelo laudo de constatação preliminar e laudo definitivo (páginas 15/16 e 17/28) que provam serem drogas as substâncias apreendidas e periciadas, bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria também é certa. DIOGO, ouvido em ambas as fases da persecução criminal, negou a prática delitiva. Na fase extrajudicial, perante a Autoridade Policial, declarou que estava de bicicleta na via pública, quando foi abordado pelos guardas municipais. Sustentou que os guardas realizaram busca pessoal e em seu bolso foi localizada a quantidade de 1 porção de maconha e 4 eppendorfs de cocaína, bem como a quantia de R\$170,50. Esclareceu que os entorpecentes eram de sua propriedade e tinha acabado de comprá-los, por sua vez, o dinheiro era oriundo do seu trabalho. Aduziu ser usuário de maconha e cocaína. Asseverou que os entorpecentes localizados próximo de onde estava não eram

de sua propriedade e não estava no local traficando (página 08). Em juízo declarou que estava no local para adquirir drogas e havia mantido contato com um adolescente e recebido 01 porção de maconha e 25 porções de cocaína quando então foi abordado pelos guardas municipais. Disse que o adolescente também foi abordado e liberado. Posteriormente os guardas localizaram a droga no local (calçada) onde o adolescente guardava. Não soube identificar o adolescente. Entregaria R\$ 110,00 para pagar as drogas que adquiriria. Disse ser usuário de maconha e cocaína. Está preso por tráfico de drogas, tendo sido abordado em travessa no Jardim Alvorada. Quando adolescente esteve internado por tráfico de drogas. A negativa do acusado restou isolada com o restante do conjunto probatório. Lado outro, conforme se delinear a seguir, a fala dos guardas municipais é coesa e segura e delinea a atuação criminosa de DIOGO, estando ele envolvido com a criminalidade desde a adolescência, conforme se extrai da documentação de página 57. Ademais, pouco tempo após os fatos, em 27.08.2021, o acusado fora preso em flagrante delito pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas (certidão de página 58), no mesmo bairro, Jardim Alvorada, revelando íntimo envolvimento com a traficância. Não é demais registrar que o acusado não comprovou atividade lícita. Com efeito, as testemunhas arroladas pela acusação, Danilo Carvalho de Ataíde e Sonia Regina Petri Domingos, guardas municipais, declararam em juízo que estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado com comportamento suspeito e decidiram abordá-lo. Ele estava sozinho no local. Na posse do acusado foram apreendidas "maconha" e "cocaína", além da quantia em dinheiro no valor de R\$170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos). O acusado disse que as drogas apreendidas consigo eram de sua propriedade e se destinavam ao próprio consumo, negando a propriedade dos entorpecentes localizados na proximidade. Asseveraram que cerca de 04 metros do local da abordagem, em um buraco na calçada, encontraram escondidas outras 32 porções de "cocaína" e 07 porções "maconha". Esclareceram que o acusado negou que as demais substâncias entorpecentes apreendidas fossem de sua propriedade, negando, também, que estivesse naquele local atuando no comércio ilegal de drogas. Afirmaram que o local é conhecido por ser palco de tráfico de drogas e que o acusado era conhecido da guarda civil e da polícia militar pelo envolvimento com o tráfico de drogas. O guarda DANILO afirmou que ele já havia sido abordado nesse mesmo local em atitude suspeita de prática de tráfico de drogas. Os depoimentos dos agentes públicos, testemunhas arroladas pela acusação, são harmônicos entre si e com aqueles colhidos na fase extrajudicial e indicam que a droga apreendida era de propriedade do acusado, que comercializava e guardava o entorpecente, já pronto para o comércio a terceiros. Por oportuno, observo que em matéria de crime relacionado a drogas como o que o acusado responde, onde o tráfico é feito de modo a se tentar não deixar vestígios, a palavra dos guardas municipais deve ter relevo e destaque. Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado. Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo,

sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto

porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87.662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de agentes públicos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009). Assim é que não se contesta a validade dos depoimentos acima delineados, que constituem prova perfeitamente aceitável. A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - confissão judicial em consonância com o restante da prova produzida - depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda e a confissão judicial do réu de que guardava porções de droga para consumo de terceiros. PENAS - primeira fase - base fixada em 1/3 acima do mínimo legal - natureza, quantidade e diversidade - segunda fase - confissão - diminuição de 1/6 - terceira fase - ausente causas de aumento ou diminuição da pena - reprimenda reformada. REGIME - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica - Beccaria - regime fechado - provimento parcial ao recurso, com determinação. (TJSP; Apelação 0003995-20.2014.8.26.0361; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 14/02/2019). APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM

RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017). PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007). PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto. (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652). A prova oral, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, é suficiente para delinear a atuação criminosa do acusado. Não bastasse a fala coesa dos agentes públicos, as circunstâncias em que os fatos ocorreram evidenciam a prática do delito em análise. Destaca-se que os guardas municipais avistaram, em local conhecido pela intensa traficância, o acusado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo, sendo encontrada na posse de DIOGO 1 (uma) poção de maconha e 4 (quatro) cápsulas de cocaína, além da quantia de R\$170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas diversas. Ainda, vasculhando o local, os agentes encontraram, nas proximidades de DIOGO e dentro de um buraco na calçada, outras 32 (trinta e duas) porções de cocaína e outras 7 porções de maconha, todas embaladas e acondicionadas de forma idêntica às que estavam em sua posse. O acusado, pouco tempo depois dos fatos, em 27.08.2021, fora preso em flagrante delito pela prática, em tese, de tráfico de drogas (certidão de página 58). Considerando a diversidade e quantidade de droga apreendida e pronta para a venda a terceiros, e alinhavados os fatos acima delineados, fica evidente que a finalidade a que se destinaria o entorpecente seria o comércio. Destaca-se que o crime de tráfico de drogas não exige a mercancia, restando caracterizado também pelas demais condutas tipificadas no dispositivo legal, dentre elas guardar drogas para fins de entrega a terceiros (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006). Anote-se, por fim, que o fato de o acusado ser usuário de drogas (o que não foi comprovado nos autos) em nada altera a conclusão supra delineada haja vista que restou comprovado à saciedade que o entorpecente apreendido seria destinado ao consumo de terceiros. Ante o exposto e pelas razões acima delineadas, são suficientes as provas produzidas para o decreto condenatório. Existe regularidade procedimental e a prova reflete os fatos denunciados, impondo-se, portanto, a procedência da ação penal, restando afastadas as teses de defesa em sentido contrário. Aplicação da pena. Passo a dosar a pena. Individualizo-a ao caso concreto. Observo a situação pessoal do acusado. Faço a sua adequação para a prevenção e para a repreensão do ilícito. A pena do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Trata-se de legislação especial, devendo ser observado o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 ("O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"). Foram apreendidas 08 (oito) porções de "Cannabis sativa L", substância vulgarmente conhecida como "maconha", além de 36 (trinta e seis) cápsulas de cocaína, sendo que a cocaína possui natureza nefasta e se mostra, em comparação a outros tipos de drogas, como a

maconha, por exemplo, mais perniciosas à saúde do consumidor o que gera, também, o desencadeamento da prática de diversos crimes para o sustento do consumo bem como onera o Poder Público como um todo, que busca incessantemente combater o câncer que assola cidades do interior paulista como Sertãozinho, o que indica a necessidade de exasperação da pena base. Face de todo exposto e com fundamento nos preceitos legais pertinentes (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59, do Código Penal), aumento a pena base em 1/6 e fixo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ausentes agravantes, presente a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que à época dos fatos o acusado, nascido em 28.04.2002, era menor de vinte e um anos de idade. Logo, diminuo a pena em 1/6 e retorno-a ao patamar mínimo legal, em observância ao disposto na súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar. Observa-se que o acusado embora primário, segundo os depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo, se dedica à prática do tráfico de drogas nesta cidade, o que se coaduna com as certidões da Vara da Infância e Juventude e Varas Criminais, sendo certo que pouco tempo após os fatos tratados nos autos, DIOGO fora preso em flagrante delito pela prática, em tese, de tráfico de drogas, o que denota tratar-se de pessoa que se dedica à atividade criminosa, traçando verdadeira escalada na criminalidade, ao que se soma o fato de que foram apreendidos dois tipos de drogas em quantidades razoáveis, sendo, portanto, incabível a redução de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e, por isso, inaplicável o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal que afastou a hediondez no delito de tráfico de entorpecentes privilegiado: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida (HC 118533, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016). Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e fixação do regime aberto. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto que não permitem a aplicação do redutor. Pena e regime prisional bem justificados e que não comportam reparo. Pedido revisional indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 0008066-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019). Apelação. Tráfico de drogas. Defesa que se conformou com a condenação e pretende a reforma da r. sentença para a fixação da pena-base no patamar mínimo, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, substituição da pena corporal por restritivas de direitos, abrandamento do regime prisional e da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade da droga apreendida que inviabiliza a aplicação do redutor. Pena, regime inicial fechado e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Pena de multa que é parte integrante da pena. Recurso defensivo não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000050-70.2017.8.26.0603; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019). Chega-se, pois, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no patamar mínimo legal, face às condições econômicas do acusado, atualizando-se a multa pela correção monetária, consoante preceitos da lei

especial, e a partir da data da prática do fato ilícito. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 - com redação dada pela Lei nº 11.464/07 -, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. No caso concreto, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, pois, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 anos de reclusão, o modo inicial fechado é o adequado à espécie, tendo em vista a aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza da droga apreendida, conduta social e personalidade voltadas à criminalidade, consoante indicado na primeira fase da dosimetria) a ensejar a aplicação do regime mais danoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (Precedentes - Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 645.638/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018; AgRg no HC 411.685/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018; HC 424.437/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito (artigo 44, do Código Penal). É incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal). Situação prisional. O réu respondeu ao processo em liberdade, estando preso por outro processo não vislumbro, no presente momento a necessidade de decretação da prisão cautelar nestes autos, razão pela qual poderá responder em liberdade. Perda de bens. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal combinado com o artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, determino a perda em favor da União (FUNAD) dos valores apreendidos por serem decorrentes da venda ilícita de drogas uma vez que não comprovou o acusado a origem lícita. Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado DIOGO EZEQUIEL ROQUE, qualificado na página 08, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelo que o condeno à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no patamar mínimo legal, face às condições econômicas do acusado, atualizando-se a multa pela correção monetária, consoante preceitos da lei especial, e a partir da data da prática do fato ilícito. Regime inicial fechado. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Recurso em liberdade. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal combinado com o artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, determino a perda em favor da União (FUNAD) dos valores apreendidos por serem decorrentes da venda ilícita de drogas uma vez que não comprovou o acusado a origem lícita. Cumpra-se o necessário. Registre-se. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pela MM. Juíza foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões.". Este termo é assinado eletronicamente pela MM. Juíza, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.